

1501076-17.2021.8.26.0594
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Érica Marcelina Cruz
Comarca: Bauru
Foro: Foro de Bauru
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 06/12/2022
... nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Bauru
Foro de Bauru
1ª Vara Criminal
Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501076-17.2021.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501076-17.2021.8.26.0594
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2268015/2021 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 20588574 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 6669/21/050 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2268015 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2268015 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 6669/21/050 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RODRIGO HENRIQUE DE MORAES
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

RODRIGO HENRIQUE MORAES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e II c/c artigo 14, II do Código Penal.

Segundo a denúncia, o acusado, no dia 30 de setembro de 2021, por volta de 23h, na Rua Jaime Moreira, número 2-16, bairro Parque Olímpico, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, tentou subtrair, para si, com destruição de obstáculo e mediante

escalada, 01 martelo de borracha, 01 adesivo plástico para tubo de PVC, 07 cotovelos de 40/38, 04 cotovelos de ½ polegada, 04 cotovelos nº 5688, 01 cotovelo de nº 50 com pedaço de cano, 01 pedaço de cano da marca tigre, 02 rodela de cano cortada e 01 pedaço de lixa, da vítima Marcos da Silva Rodrigues, que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

Auto de prisão em flagrante (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 25/28), auto de exibição/apreensão/entrega/avaliação (fls. 29/30), relatório policial final (fls. 75/77), laudo pericial (fls. 264/272).

Pelo crime, o réu foi preso em flagrante (fls. 05).

Em audiência de custódia, realizada em 01 de outubro de 2021, a prisão preventiva do réu foi convertida em prisão preventiva (fls. 64/68).

Pela decisão de fls. 81/82, a denúncia foi recebida em 09 de outubro de 2018, e determinada à citação dos réus.

O réu foi citado (fls. 93) e apresentou defesa prévia (fls. 98).

O recebimento da denúncia foi mantido (fls.99/103).

Na ocasião da audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada em 09 de março de 2022, foram ouvidas vítimas e as testemunhas. A testemunha Flávio Henrique da Silva foi dispensada. Em seguida, ocorreu o interrogatório do réu.

Em decisão de fls. 137/145, foi mantida a prisão preventiva do réu.

Em decisão de fls. 180/189, foi mantida a prisão preventiva do réu.

Em decisão de fls. 215/216 foi indeferido o pedido defensivo e mantida a prisão preventiva do réu.

O Ministério Público, em sede de memoriais, fls. 245/250, pugnou, em suma, pela procedência da ação nos termos da denúncia. Pugnou também pela juntada do laudo pericial nos autos. Argumentou que a autoria e a materialidade restaram demonstrada, após detida apuração acerca dos fatos. Afirmou que as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo foram demonstradas em juízo diante da prova testemunhal. Corrobora a condenação, auto de prisão (fl.05), o boletim de ocorrência (fls. 25/28), auto de exibição e apreensão (fls.29/30), relatório final (fls.75/77), além das testemunhas ouvidas em juízo. Sustentou que na primeira fase da dosimetria, o acusado possui antecedentes e que por se tratar de furto duplamente qualificado (rompimento de obstáculo e escalada), uma delas devem servir como circunstância judicial desfavorável. Sustentou ainda que na segunda fase, trata-se de réu reincidente específico, tendo presente a agravante de crime praticado em época de pandemia. Requereu que na terceira fase, a pena deve ser aumentada em 1/3 pelo repouso noturno e diminuída em 1/3 pela semi-imputabilidade (fls.224/236) e mais 1/3 pela tentativa. Sugeriu a pena de dois anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, além da pena de multa. Por fim, inviável a substituição por pena restritiva de direitos, diante da ausência de requisitos subjetivos.

Já a Defensoria, fls. 254/263, por sua vez, requereu que seja julgada improcedente a ação penal com a consequente absolvição por falta de provas de autoria. Sustentou que a acusação não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é próprio. Argumentou que necessária se faz a absolvição do acusado, pois inexistem provas suficientes para sua condenação, em respeito ao princípio in dubio pro reo, com fulcro no artigo 386, V, do Código de Processo Penal. Requereu que seja aplicada a atenuação

da pena, por consequência jurídica do caso em apreço. Requereu ainda a redução da pena em razão da semi-imputabilidade apontada em laudo a fls. 224/236, em proporção de 2/3 ou, conforme recomendação do laudo de insanidade mental, o tratamento em regime ambulatorial (CAPS-AD), visto que a capacidade de determinação restava prejudicada na época do delito. Sugeriu que na primeira fase da dosimetria, requer seja a pena base do acusado fixada no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, a reincidência não deve ser considerada, eis que constitui inegável direito penal de autor, constituindo-se em manifesto "bis in idem". E na terceira fase da dosimetria, entende-se ser cabível a redução na proporção de 2/3 em razão da tentativa, visto que o acusado não obteve a posse mansa e pacífica do bem, nem sequer chegou próximo da consumação do delito. Com isso, merece a pena ser reduzida em 2/3, na forma disposta no artigo 14, II do Código Penal, considerada extensão do iter criminis supostamente percorrido. Pugnou que, em relação ao regime inicial do cumprimento da pena, que se dê a observância do artigo 33, § 2º, do Código Penal e das súmulas 718 do STF e 440 do STJ, ou, ainda, em atenção a súmula 269 do STJ, em atenção ao quantum de pena que ao final restará aplicada ao acusado, visto a reincidência. Por fim, requereu a absolvição do acusado pela falta de provas de autoria, subsidiariamente, e que caso se entenda pela condenação do acusado, requereu pelo reconhecimento da causa de diminuição em razão da semi-imputabilidade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelos seguintes documentos: Auto de prisão em flagrante (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 25/28), auto de exibição/apreensão/entrega/avaliação (fls. 29/30), relatório policial final (fls. 75/77), laudo pericial (fls. 264/272).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

Em juízo, vítima Marcos da Silva Rodrigues, sob o manto do contraditório (mídia SAJ), em resumo, disse que o acusado invadiu sua residência. Narrou que um vizinho mandou mensagens para ele dizendo que suspeitava ter alguém dentro de sua residência, pois tinha escutado barulhos. Relatou que ao chegar o local dos fatos, avistou o acusado dentro de sua residência. Reportou que, quando o acusado o viu, tentou pular o muro para fugir, porém, acabou caindo e se machucando. Afirmou que junto com o acusado tinham alguns pertences que ele tinha furtado da residência, mas que conseguiu recuperar. Afirmou que o acusado forçou a entrada dentro da residência, danificando portas e janelas. Relatou também que o acusado estourou grades, portas e janelas. Reportou que a altura do muro é de, aproximadamente, 2,80m. Narrou que o acusado tentou furtar os pertences de encanamento, da parte hidráulica, e vários itens de encanamento. Afirmou que há um desnível entre o lado de dentro e o lado de fora da residência, em relação ao muro. Relatou que a casa estava na fase final da obra, onde as janelas eram de alumínio, então havia 'tampões de proteção da grade', na qual o acusado arrancou e, em seguida, estourou a grade das janelas para adentrar a residência.

Em juízo, a testemunha PM Guilherme Reuel da Silva Castro, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, disse que se lembra da ocorrência. Narrou que no dia dos fatos o COPOM reportou a ocorrência para a sua viatura. Disse que o seu CGP (Comandante de Grupo de Patrulha) estava mais próximo ao local e, por esta razão, deu o primeiro atendimento a ocorrência. Relatou que, ao chegar ao local, o autor do furto já estava contido pelo proprietário da residência e pelos vizinhos. Argumentou que, segundo relato do proprietário da residência, o seu vizinho teria

visto um rapaz entrando na residência para a prática do furto, e, em seguida, ligou para ele. O proprietário da residência relatou, ainda, que foi até sua residência, avistou o indivíduo, que correu para o fundo da casa e, ao tentar subir no muro para fugir, acabou caindo. Relatou que após isso, o proprietário da residência gritou os vizinhos, que efetuaram a detenção do autor. Afirmou que tudo isso aconteceu antes da Polícia Militar chegar. Reportou que a residência onde ocorreram os fatos, se tratava de uma casa em construção, com um muro alto e um portão bem fechado. Alegou que, com base na descrição do local, para o indivíduo ter entrado na residência, supostamente, havia pulado o muro. Narrou que, ao chegar ao local dos fatos, o indivíduo estava no chão com uma sacola plástica ao seu lado, com alguns materiais de construção dentro.

Em juízo, a testemunha PM Dhiego Andriu Camargo, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, disse que se recorda da ocorrência. Narrou que a ocorrência chegou ao seu conhecimento quando estava na viatura e que, ao chegar ao local dos fatos, o seu CGP já estava dando os primeiros atendimentos. Relatou que foi informado sobre o furto de uma residência em obras. Narrou que os vizinhos ligaram para o proprietário, que, ao chegar ao local, encontrou o indivíduo, dentro da residência. Relatou que o réu estava residindo a duas quadras do local dos fatos. Reportou, ainda, que o indivíduo tentou fugir, pulando o muro, mas veio a cair e fraturou a perna. Disse que, diante dos fatos, conduziram o indivíduo à UBS e, lá, ele passou por cirurgia. Afirmou que, naquele mesmo dia, foi registrado o boletim de ocorrência. Narrou que foi encontrada, junto ao indivíduo, uma sacola plástica, com algumas ferramentas e materiais de construção em seu interior. Relatou que o acusado quebrou a janela da residência para poder furtar os objetos citados. Disse que não conhecia os indivíduos no meio policial.

Em juízo, a testemunha Osvaldo Alves de Aragão Júnior, em síntese, disse que o local dos fatos é a residência de um vizinho. Narrou que, por volta das 23h, seus cachorros estavam latindo muito e, em seguida, ouviu um barulho semelhante a algo caindo. Disse que 'os cachorros dos vizinhos também latiam muito'. Relatou que, em seguida, saiu de sua residência para ver o que estava acontecendo e, nisto, já viu um rapaz, caído. Afirmou que, quando saiu, já tinham algumas viaturas policiais e também o seu vizinho, proprietário da residência, no local dos fatos. Relatou que o local dos fatos já havia sofrido outros dois furtos. Soube que o acusado tentou pular o muro e caiu, porém, não viu acontecendo. Reportou que outro vizinho, ao também ouvir os barulhos, ligou para a polícia. Soube que o acusado entrou na casa, estourou duas ou três portas, que fez muito barulho, e, por este motivo, 'os cachorros latiam muitos e a vizinhança saiu para ver o que estava acontecendo'. Relatou que, junto com o acusado, tinha uma sacola plástica, com coisas pertinentes à obra, mas não sabe exatamente o que era. Narrou que pelo o que se recorda, dentro da sacola plástica, tinha tubulação, torneiras, dentre outras coisas.

No interrogatório judicial, o réu Rodrigo Henrique de Moraes, em síntese, negou a prática do delito. Disse que estava passando, na rua, quando sentiu vontade de urinar, parando no muro da residência dos fatos. Relatou que, algumas quadras abaixo, o proprietário da residência, o atropelou com seu veículo, chegando a quebrar o vidro do veículo e fraturar seu fêmur. Narrou que o proprietário da residência o levou de volta para a residência em obras, o acusando de furtar, e jogou alguns materiais pertinentes à obra. Afirmou que estava sob o efeito de drogas no dia dos fatos. Disse que, quando os policiais militares chegaram ao local dos fatos, ele estava dentro do porta-malas do veículo do proprietário da casa. Narrou que os policiais pediram para ele sair do porta-malas e ele se jogou na calçada, pois já estava com o fêmur quebrado. Afirmou que os mesmos policiais já o tinham prendido uma vez. Relatou que 'seu fêmur fraturou em três lugares'. Afirmou que 'não tinha precisão de furtar a residência, pois, no dia dos fatos, estava com dinheiro e drogas no bolso'. Relatou que foi agredido pelos policiais. Afirmou que tem antecedentes criminais também pela prática de furto e roubo. Relatou que tem 39 anos e tem a profissão de pintor. Relatou que já foi internado em clínica de

reabilitação, mas ficou somente três meses lá. Narrou que é usuário de drogas há 06 anos. Reportou que tem dois filhos e que é divorciado há 12 anos. Relatou que seu filho mora com ele e com sua genitora. Narrou que está preso há 6 meses.

Como se denota, os policiais destacaram que o réu foi o autor da conduta e apresentaram depoimentos coesos e uniformes.

Ora, os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP.

Por isso, os relatos são cancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

Com efeito, o acusado pulou um muro para ter acesso à subtração dos objetos.

Ademais, o réu foi surpreendido, ainda no local, pela vítima Marcos da Silva Rodrigues, a testemunha Osvaldo Alves de Aragão Júnior, bem como pelos policiais Guilherme Reuel Castro e Dhiego Camargo.

Importante citar que o local se tratava de uma construção.

No caso concreto, pulou um muro e, após romper portas e janelas, passou a subtrair os bens.

A dinâmica é confirmada pela prova oral colhida, bem como, pelo exame pericial.

Às fls. 270/271 percebe-se o rompimento das grades das janelas.

De outro lado, o muro, segundo relatos, tinha a altura de mais de dois metros, tanto que o acusado, ao tentar fugir mediante a escala, caiu e se machucou.

Sob outro vértice, a prova revelou que o delito foi tentado, entretanto, na menor extensão.

O acusado foi surpreendido pelo proprietário e vizinhos ainda no interior do local, mas os objetos já estavam acondicionados em uma sacola, com a qual o acusado tentou fugir.

Assim, a redução deve dar-se na menor extensão, isto é, 1/3.

Sob outro aspecto, deve o réu permanecer em custódia.

O acusado Rodrigo Henrique de Moraes possui três condenações, duas caracterizadoras de maus antecedentes (0058592-19.2003 e 0062314-61.2003) e uma que representa reincidência 1500336-30.209, fls. 34/47).

Por isso, a manutenção da custódia serve para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nessa senda:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACAUTELADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PROPORCIONALIDADE CONSTATADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento este chancelado por esta Corte, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício, o que não se coaduna à hipótese dos autos.

2. Constrangimento ilegal não configurado, pois, conforme exegese teleológica do art. 282, caput, incisos I e II, c.c. as cautelares pessoais não prisionais estatuídas no art. 319, ambos do Código de Processo Penal, contornados pela sistemática estatuída na Lei n. 12.403/11 e sob a égide da proporcionalidade (formal e material), afigura-se suficiente e adequada, conforme as peculiaridades do caso concreto, a imposição ao acautelado da proibição de ingestão de bebidas alcoólicas e uso de estupefacientes quando este confessa, no bojo da persecução criminal, ser usuário (dependente químico) e ter praticado o delito sob os efeitos de tais substâncias, as quais potencializam - caso não evitadas - o risco no cometimento de novas infrações.

3. Na hipótese, a necessidade e adequação das medidas não prisionais em testilha foram justificadas pelas instâncias ordinárias com base nas circunstâncias do fato e nas condições pessoais do agente, permeadas pela confissão da prática delitiva de suposto furto "motivada pela fissura da droga" e, conforme evidenciado na audiência de custódia, consulta ao SISP revela que este teve outras duas ocorrências policiais anteriores pela prática da mesma espécie de crime, malgrado ser tecnicamente primário.

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, 5ª Turma, HC 395336 / SC, relator ministro Jorge Mussi, julgado em 24/04/2018)

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu possui antecedentes criminais, como dito.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

De outro lado, uma das duas qualificadoras pode ser utilizada como circunstâncias perniciosas.

No aspecto:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL – Furto Qualificado (artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal). Sentença condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e das testemunhas. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Condenação mantida. Dosimetria. Qualificadoras bem demonstradas. Particularidades do caso que impõem a exasperação da pena-base. Regime semiaberto mantido. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Afastada a indenização fixada nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Recurso parcialmente provido. (TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1502739-15.2020.8.26.0536, relator Des. Freddy Lourenço Ruiz Costa, julgado em 26/07/2022)

Deste modo, a pena deve ser exasperada em metade, atingindo 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na mesma fase, há feitos que representam reincidência.

No aspecto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. DECISUM RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Foi denegada a ordem de habeas corpus pleiteada, pois o entendimento firmado no decisum recorrido está em harmonia com o desta Corte, de que a multirreincidência do réu justifica validamente a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea.

2. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne os fundamentos da decisão combatida, conforme entendimento firmado pela Corte Especial.

3. Agravo regimental não conhecido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 654637 / MS, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 22/06/2021)

Por isso, na fase intermediária, a pena deve ser agravada em 1/3, perfazendo 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) diárias.

Ainda na segunda fase, quanto à agravante do “estado pandêmico”, deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação – Tipicidade formal e material da conduta presentes – Afastada a

agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito - Não reconhecimento da participação de menor importância - Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor - Concessão de regime inicial aberto - Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito - Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Na derradeira, a majorante do "repouso noturno" deve ser aplicada.

Ocorre que em razão da menor vigilância a citada causa de aumento é incidente, ainda que estabelecimentos comerciais.

Nesse sentido:

Ementa: Furto qualificado - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Absolvição por fragilidade de provas - Impossibilidade - Condenação mantida. Repouso noturno - Crime praticado em período de menor vigilância - Majorante pode ser reconhecida mesmo em área comercial - Pleito de afastamento desacolhido. Pena-base acima do mínimo legal - Possibilidade - Duas qualificadoras, uma delas utilizada como circunstância judicial desfavorável - Recurso provido em parte para reduzir o acréscimo aplicado. Continuidade delitiva com furto apurado em processo distinto - Feitos que não foram reunidos na origem e geraram apelações distribuídas em Câmaras diferentes - Aplicação do artigo 71 do Código Penal deve ser realizada no Juízo das Execuções - Recurso provido em parte para afastar o acréscimo do crime continuado

(STJ, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0000197-85.2018.8.26.0660, relator Des. Klaus Marouelli Arroyo, julgado em 19/08/2022)

É o caso, ainda, da manutenção da causa de aumento.

É dizer, em casos de delitos qualificados, já mais graves, jamais a reprimenda seria justa, pois a majorante jamais seria aplicada.

Ou seja, haveria patente desproporcionalidade, na aceção da proibição de proteção ineficiente.

Além disso, eis a redação do art. 155, §1º do Código Penal: § 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

Da simples leitura, possível concluir que não há limitação ao delito simples.

Tanto é assim, que o §4º assim preconiza: § 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

Na mesma linha, a Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal, de 04/11/1940, item 56: É prevista como agravante especial do furto a circunstância de ter sido o crime praticado "durante o período do sossego noturno".

Portanto, a aplicação visa homenagear a individualização da pena, verdadeiro direito fundamental.

Por isso, a pena é aumentada em 1/3, atingindo, 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) diárias.

Na mesma extensão, deve ser diminuída em 1/3, perfazendo, 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Por fim, ainda na derradeira, o laudo pericial de fls. 227/236 concluiu que o

acusado detinha a capacidade de entendimento preservada, contudo, a determinação prejudicada.

O mesmo exame citou que há transtorno mental e comportamental decorrente do uso de múltiplas drogas, síndrome de dependência, sendo que, após a abstinência desde a prisão, ambas as capacidades estão híidas.

Por isso, em razão da semi-imputabilidade, a pena deve ser reduzida em mais 1/3, atingindo, em definitivo, 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica do réu.

Os maus antecedentes, a reincidência e as circunstâncias de cometimento dos delitos, denotam que o regime mais gravoso é o único apto a reprimir, e, principalmente, ressocializar o réu.

Além disso, é responsabilizado por delito análogo (1500860-56.2021), cometido pouco antes dos fatos, mais precisamente em 07/08/2021, em relação ao qual teve a liberdade concedida.

No aspecto:

Ementa: PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Pretendida absolvição por atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, redução da pena-base, compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, afastamento da agravante referente à calamidade pública e a fixação do regime inicial semiaberto. Impertinência. 1) Absolvição por atipicidade da conduta. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. O Princípio da "insignificância" ou da "bagatela" não possui previsão no ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual é de impossível aplicação. De todo o modo, valor das "res" (R\$ 70,00) que não pode ser tido como insignificante ou irrisório, ademais, observados, aqui, a "ousadia" e o "atrevimento" no comportamento externado pelo réu, além de sua condição de reincidente específico, incompatíveis com a benesse, pela vertente que a admite. 2) Dosimetria das penas. A) Redução da pena-base. Impertinência. A fixação da basilar acima do mínimo legal se justificou pelos maus antecedentes, inclusive em delito da mesma espécie, bem como pela alta reprovabilidade da conduta. B) Compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea ou sua exasperação em índice "mínimo". Impossibilidade. Tratando-se de reincidência específica, a denotar a necessidade de imprimir maior rigor na censura, descabida é a compensação integral da respectiva agravante com a atenuante da confissão espontânea, destacando-se, ainda na escolha do índice, uma segunda agravante. C) Afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal. Impertinência. Crimes cometidos durante estado de calamidade pública, reconhecido em razão da pandemia do COVID-19. Circunstância objetiva, que, de qualquer forma, revela maior reprovabilidade da conduta, haja vista direta ligação com a conduta, ou seja, com aproveitamento claro da situação, por suposta redução do organismo repressor do Estado. 3) Inviável alteração do regime determinado para início de cumprimento da pena. Acusado, reincidente específico. Clara necessidade de imposição do fechado para adequadas repressão e ressocialização. Negado provimento. (TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1500384-40.2020.8.26.0598, relator Des. Alcides Malossi Júnior, julgado em 26/07/2022, g.n.)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão inicial deduzida na ação penal e,

desta feita, CONDENO o réu RODRIGO HENRIQUE MORAES, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no importe de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, I e II c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Nego ao acusado o recurso em liberdade, pelos motivos acima consignados.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embargos que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C

Bauru, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA